

1509195-09.2022.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... certa em acusá-lo de transportar drogas, para tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509195-09.2022.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509195-09.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2249544/2022 - 04º D.P. AMERICANA, 27370729 - 04º D.P.

AMERICANA, 2249544 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISAC IZZYNYLON DA SILVA PORTO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

FELIPE PENHA CORREA e ISAC IZZYNYLON DA SILVA PORTO estão sendo processados como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, acusados de no dia 12 de setembro de 2022, por volta das 22h20, na Rua Perdizes, 58, bairro Jardim dos Lírios, nesta cidade, transportarem, com a finalidade de tráfico, drogas, 425 porções de cocaína, pesando cerca de 181 gramas, substâncias que provocam dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi instruída com Inquérito Policial.

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se defesa e acusação.

A denúncia foi recebida em 21 de outubro de 2022 (fls. 261/263).

Na instrução, foram inquiridas duas testemunhas comuns e uma testemunha de Defesa.

Ao final, os réus foram interrogados.

Sem mais requerimentos, nos debates, a acusação requereu a procedência da denúncia,

com a condenação dos réus, provadas as ocorrências dos crimes, materialidade e autoria de cada qual. Discorre sobre penas e regimes.

A Defesa de Felipe requer a absolvição por insuficiência de provas, porque o réu nada traria com ele, drogas ou objetos, a indicar tráfico. Autoria foi assumida por corréu, que estaria de carona com ele e sem o incriminar. Empreendeu fuga a mando de Isac e que então o avisou sobre as drogas. Residiam no bairro. Para o caso de condenação, pretende redução da pena no patamar máximo (2/3) porque primário (artigo 33, par. 4º), com regime aberto e substituição por restritivas de direito. Detração (fls. 313/319).

Isac alegou ser nulo o processo, por abordagem sem justificativa e arbitrária. A nulidade comprometeria a ação penal. Para o caso de condenação, pretende a consideração da confissão e recurso em liberdade (fls. 338/344).

É o relatório.

DECIDO.

A preliminar não procede.

Pelo que se depreende dos autos, Isac admitiu que estava em situação que exigia intervenção dos agentes da autoridade, a qual, ocorrida e com revista, resultou na apreensão de droga, ocultada em sacola.

Havia indicativo de ocorrência de crime, em tese, que é permanente (tráfico) para a realização da prisão em flagrante (não para a busca ou revista, como é a hipótese) assim, sofre atenuação pelo interesse coletivo em se apurar, prevenir e punir a prática de crime.

A abordagem não foi gratuita ou ocasional, mas movida por policiamento preventivo. O réu Isac teria admitido para os militares que transportava entorpecentes, cuja revista restou positiva para o encontro de drogas, situação de crime.

De lembrar, também, que estando o policial militar no regular exercício da função preventiva, exatamente para proteção do coletivo, não carece de mandado para abordar e revistar, segundo o critério da discricionariedade imediata que lhe confere o Estado para cumprir o mister.

Bem daí a regra do artigo 244 do Código de Processo Penal:

Art. 244. A busca pessoal independe de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Apenas provado despropósito na ação profissional desenvolvida, o que não ocorreu e foi produzido em termos de prova, pode dar ensejo à nulidade perseguida pela Defesa.

Incontroverso, também, que o policiamento preventivo e a revista imediatamente realizada resultou em apreensão de drogas, o que também e de resto, afinal, não foi sequer negado pelos réus.

Não se tratou de busca investigativa, quando o objetivo estatal, por meio de seus agentes, é relacionar a pessoa abordada a crime ocorrido, exigindo-se então a fundada suspeita a legitimar a ação.

Diversamente, como é o caso destes autos, a busca preventiva se dirige a fundada suspeita, portanto, funciona como garantia de que a pessoa não será, aleatoriamente, relacionado à prática de uma infração penal investigada, sem possuir relação com o fato.

Já a busca preventiva visa manter a ordem pública, evitar ilícitos, dar efetividade às leis e se dirige a todos, indistintamente.

Exigir fundada suspeita sem distinguir a finalidade da ação estatal é desconsiderar texto legal vigente, além de inverter a consideração de presunção de legitimidade dos atos realizados pela administração pública e seus agentes, para considerá-la em regra abusiva.

No mérito, a ação penal é procedente, parcialmente e quanto a Isac.

Preso em flagrante, Felipe alegou que tinha acabado de chegar do serviço, trabalhou das 08 até às 18 horas, com entrega de peça de auto elétrica. Após tomar banho e jantar, foi para a rua. Na Praça Oscar Inácio de Sousa, encontrou Isaac, que pediu uma carona até a casa dele. Logo em seguida, foram abordados pela viatura da força tática. As drogas foram encontradas com o Isaac, que havia dispensado as

substâncias antes de pararem a moto. Somente tomou conhecimento de que Isaac estava com as drogas, quando a viatura da polícia os perseguiu e o seu colega pediu para que tentassem fugir. Não tinha passagem pela polícia, era apenas usuário de maconha. Nunca mexeu com o tráfico de drogas, trabalhava com carteira assinada, até ser demitido, há dois meses (fls. 07).

Também no inquérito, Isac deliberou confessar. Pela manhã, bateu o carro e foi à Delegacia. Após, recebeu uma proposta para fazer o transporte da droga, iria levá-la até a cidade de Sumaré e ganharia cem reais. Foi até a Avenida Cillos, pegou a mercadoria com um rapaz no estacionamento do São Vicente. Desceu à pé e na Praça Oscar Inácio de Sousa, encontrou Felipe. Pediu uma carona até a sua casa. Em seguida, cruzaram com a viatura da força tática.

Tentaram se evadir da polícia, avisou o colega que precisava sair, portava drogas. Até então, o Felipe não sabia sobre a existência da droga. Foram alcançados pela viatura e abordados.

Os policiais encontraram a sacola que tinha dispensado em uma casa e foram levados para o distrito policial (fls. 08).

No interrogatório judicial, Felipe alegou que trabalhou o dia todo, era segunda-feira. Chegou do serviço, foi até a sua casa e tomou banho. Foi jantar com a sua mulher. Quando voltava para a sua casa, em frente à Praça, viu o Isac e ele o chamou, pedindo carona até a casa dele. Até falou que precisava dormir, tinha que acordar cedo para trabalhar no dia seguinte, mas Isac insistiu e aceitou. No trajeto, quando estavam em frente ao Supermercado, passaram pela polícia. A viatura mandou parar, foram abordados um quarteirão para baixo. Isac lhe disse que estava com drogas. Iria parar, tinha habilitação. Foram levados até a Delegacia.

No seu interrogatório judicial, Isac voltou a confessar. Acordou por volta das 10 horas para ir até a escola João XXIII. Faria uma prova, cursava o ensino médio. No trajeto, colidiu o veículo da sua esposa contra uma árvore. O carro teve danificado o farol direito, o paralama direito e o para-choque. Ficou desesperado para poder arrumar o carro, utilizado para levar a bebê da sua irmã até o hospital, para tomar vacinas e fazer exames. Também usava o veículo para trabalhar, era chapeiro, trabalhava em Piracicaba, Valinhos, na Anhanguera, em vários lugares. Depois que bateu o veículo, foi apresentado na Delegacia, saiu de lá por volta das 18 horas. Quando chegou em casa, recebeu a ligação de um rapaz, que pediu para que o encontrasse no estacionamento do São Vicente, da Avenida Cillos. Ele pediu que levasse uma mercadoria até determinado local, por ele informado. Em troca, receberia cem reais. Foi até o local, pegou a mercadoria e a colocou na cintura. Descia a Rua das Rosas, na altura da Praça Oscar Inácio de Souza, viu o Felipe. Chamou o colega e pediu uma carona até a sua casa. Felipe alegou que tinha de trabalhar cedo, mas aceitou. Passavam pela Rua das Azaleias, viram uma viatura da polícia militar na Rua das Hortênsias. Passaram pelos policiais, olhou para trás e percebeu que estavam sendo perseguidos. Felipe era habilitado e a documentação da moto dele estava em ordem, ele queria parar para a viatura. Pediu para ele fugir, 'estava com um flagrante em cima'.

Assim que dobraram a Rua dos Lilases e desceram a Rua dos Perdizes, dispensou uma sacola. Foram abordados e admitiu que a sacola era sua. As drogas foram encontradas pelos policiais. Foram apresentados na Delegacia de Polícia.

Wagner Pereira da Luz Gonçalves, policial militar, adiantou reconhecer os acusados na tele audiência. Esclareceu que a equipe realizava patrulhamento de força tática, pela Rua das Hortênsias. No cruzamento com a Rua das Azaleias, na praça da Cidade Jardim, local conhecido pelo comércio de drogas, depararam-se com uma motocicleta, ocupada por dois homens. Eles trafegavam em alta velocidade, sentido ao bairro Jardim dos Lírios. Ao passarem pela viatura, os ocupantes da moto olhavam a todo o momento para trás. Observaram que o passageiro da motocicleta carregava algo nas mãos, de cor amarela. Iniciou o acompanhamento, acessaram a Rua Perdizes e o passageiro da motocicleta lançou uma sacola amarela em cima de um telhado de um sobrado, na altura do numeral 34. Os homens prosseguiram, mas conseguiram os interceptar pelo número 58 da mesma via. Os homens ofereceram certa resistência à abordagem. Na revista, nada de ilícito foi encontrado em poder dos acusados.

Prosseguiu na diligência para buscar o objeto jogado sobre o telhado. Localizou uma sacola, com 25 kits de cocaína, 12 kits de cor branca e 12 de cor amarela. Era uma droga mais forte (cocaína). Indagados, o Isac, passageiro da moto, assumiu a posse da droga. Isac disse que tinha uma dívida com os traficantes do bairro. A função do Isac era pegar aquela droga e deixar na residência dele. No dia seguinte, a droga seria distribuída. Já o Felipe, o condutor da moto, admitiu que sabia que a droga estaria com Isac. Detalhou que estava indo até a casa do Isac, para deixar as substâncias. Felipe não assumiu a propriedade dos entorpecentes. Diante dos fatos, deram voz de prisão aos acusados e os conduziram até o plantão policial. A equipe era composta por quatro policiais. Enquanto os colegas realizaram a abordagem e a revista nos acusados, retornou rapidamente até o local em que foi dispensada a sacola, a uns quinze ou vinte metros, na mesma via. A sacola estava em cima do telhado da área, um sobrado. A motivação da abordagem eram as fundadas suspeitas, devido a velocidade na condução da moto, em local de traficância e pelo fato do passageiro da moto sempre olhar para trás, com um objeto amarelo nas mãos. Outro policial militar, Leonardo Regis Gonçalves Batista, ratificou a versão, harmônica e coerentemente. Adiantou reconhecer os acusados na tele audiência. Destacou que patrulhavam pelo bairro Cidade Jardim, quando no cruzamento da Rua das Azaleias com a Rua das Hortênsias, avistaram uma moto Honda, na cor verde, ocupada por dois rapazes. Suspeitou de algo ilícito, o passageiro segurava um objeto, com as duas mãos. Decidiram pela abordagem e a motocicleta empreendeu velocidade. O passageiro lançou uma sacola plástica, tipo de supermercado, sobre um telhado de uma residência, na via. Conseguiram fazer a abordagem na Rua Perdizes. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado com os acusados. O sargento Gonçalves retornou ao local em que o objeto foi dispensado e recuperou a sacola de drogas, com vários kits de cocaína. Prontamente, Isac disse ser o proprietário das drogas. O piloto da moto alegou que eles foram até um local para buscar as drogas. Eles se deslocavam até a casa do Isac, para deixar essa droga lá. Deram voz de prisão aos acusados, conduzidos até a Delegacia de Americana. A esquina fazia parte de uma praça, situada no bairro Cidade Jardim, com grande volume de ocorrências de tráfico de drogas. Os acusados cruzavam justamente essa via, em alta velocidade. Ao avistarem a viatura, os réus ficaram assustados e empreenderam mais velocidade na motocicleta. O ocupante da garupa, olhava para trás o todo tempo, para ver se a viatura estava atrás deles. Não conhecia os acusados. A testemunha de Defesa Luiz Gustavo da Silva Alves alegou que o Felipe trabalhava de segunda a sexta-feira, das 08 horas às 18 horas. Ele estava aprendendo o trabalho de coordenação da equipe, estratégia e logística. Felipe era muito prestativo, chegava antes do horário, fazia tudo para que a operação desse certo. Felipe iniciou as suas atividades no dia 26 de julho de 2022, ele veio direto de outro emprego. Enfim, pela análise do contexto probatório, ressoa indubitosa a responsabilidade criminal de Isac.

Esse rapaz estava na garupa da motocicleta, era quem segurava a sacola e foi quem a dispensou, em fuga, em cima de telhado de casa. Abordado, também confessou ser dele a droga.

O corréu Felipe, piloto, alegou ter dado carona para Isac, ter tomado conhecimento de que esse rapaz levaria droga apenas quando do aparecimento da polícia e negou envolvimento com o tráfico.

A sua versão, desde o início, foi reiterada por Isac, que não procurou se exculpar. Assim, há dúvida ao menos razoável sobre a cooperação de Felipe no tráfico, pendendo em seu prol a solução absolutória.

Na jurisprudência:

Se não houver certeza, é de rigor a absolvição (STF, AP 427/SP, Tribunal Pleno, rela. Mina. Carmen Lúcia, j. 4-11-2010, DJe 122, de 28-6-2011).

“A condenação criminal não pode ser apoiada em mera presunção, desacompanhada de outros elementos de convicção” (STF, AP 330/SP, Tribunal Pleno, rel. Min. Sydney Sanches, j. 24-10-2002, DJe de 5-9-2003).

“Não existindo, nos autos, prova judicializada suficiente para a condenação, nos

termos do que reza o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição do recorrente" (STJ, REsp 1.253.537/SC, 6ª T., rela. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 1º-9-2011, DJe de 19-10-2011).  
Helena Cláudio Fragoso (Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4ª edição, página 506), ensina: "Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade".

Quanto a Isac, há a confissão, sem ressalvas.

O auto de exibição e apreensão também confirma a apreensão da droga, na quantidade informada na denúncia.

Mesmo que não houvesse sido pilhado vendendo a droga, a denúncia é certa em acusá-lo de transportar drogas, para tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Agente que não comercializou a droga - Caracterização pela simples guarda, pois o tipo do art. 12 da Lei 6.368/76 é de conteúdo variado ou misto alternativo" (TJRS, RT 745/633).

E, por pertinente: "ENTORPECENTE - Tráfico - Caracterização - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade da prática de efetivo ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito a substância entorpecente, para finalidade de venda. Inteligência do art. 12, caput, da Lei 6.368/76" (TJSP, RT 793/576).

A versão dos policiais militares, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES.

A materialidade da infração, no tráfico, foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), pelo laudo de constatação (fls. 18/20), pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 177/179).

Daí porque de rigor a condenação, de Isac.

Fixação das penas.

O réu Isac é reincidente (vg. Processo nº 1500138-79.2019.8.26.0630 - 1ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, incurso no Art. 33 § 4º do SISNAD; com trânsito em julgado para a Defesa em 04/03/2020), o que será considerado na segunda fase.

Fixo a pena base no mínimo.

Na segunda fase, está presente a agravante da reincidência, mas confessou espontaneamente, com peso na fundamentação e conclusão condenatória. Compenso as circunstâncias, mantendo inalterada a pena base.

Em terceira e última fase, impossível redução da pena, com base no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, porque Isac é reincidente.

O réu Isac deverá cumprir pena no regime inicial fechado.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu para condenar: a) ISAC IZZYNYLON DA SILVA PORTO, às penas de cinco (05)

anos de reclusão, regime inicial fechado e quinhentos (500) dias-multa, piso, por infração ao artigo 33, 'caput', da Lei 11.343/2006, c.c. artigo 61, I do Código Penal; b) absolver FELIPE PENHA CORREA da imputação contida na denúncia, o que faço com fundamento no artigo 386, IV do Código de Processo Penal.

Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Condene o réu Isac nas custas do processo, que arbitro em 100 UFESPs, na medida em que constituiu advogada, sem comprovação de que fosse hipossuficiente (fls. 127). Vinculado o numerário apreendido com o crime cometido, decreto a sua perda em favor da União, bem como os objetos apreendidos, ficando autorizado, quanto a estes últimos, doação ou destruição, acaso inservíveis ou sem valor econômico, o que será certificado.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Isac foi preso em flagrante, teve a sua prisão preventiva decretada. Agora, sentenciado o processo, interessa a prisão para a eficaz aplicação da lei penal, reincidente e com regime inicial fechado em relação ao crime de tráfico de drogas. Preso preventivamente e tendo respondido a todos os atos do processo recluso, deve assim permanecer, para garantir a eficaz aplicação da lei penal, a par de manutenção da ordem pública, rotineiramente abalada por crimes de gravidade e hediondo, como o tráfico.

(- HABEAS CORPUS ". ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. Réu que permaneceu no cárcere durante toda a marcha processual. Condenação. Manutenção na prisão em virtude da sentença condenatória. Entendimento pretoriano prevalente. Legalidade. Ordem denegada. (TJ-MG; HC 1.0000.05.426655-6/000; Juiz de Fora; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro; Julg. 27/10/2005; DJMG 24/11/2005).

"Não fere o princípio da presunção de inocência a determinação de que o sentenciado se recolha à prisão para aguardar o julgamento de recursos que, em regra, são desprovidos de efeito suspensivo" (STJ, HC 10.313 SP 5ª T., Rel. Edson Vidigal, 09.11.1999, vu DJ 13.12.1999, p. 165).

E também da mesma Corte: "O Plenário do STF já firmou o entendimento de que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos não assegura, de modo irrestrito, o direito ao réu de recorrer em liberdade, ressalvando o disposto na Constituição e nas leis de acordo com ela promulgadas" (RHC 9.342-SP 5ª T., Edson Vidigal 14.12.1999, vu DJ 21.02.2000, pág. 142).

Nesse sentido é a Súmula 9 do STJ e a doutrina (Guilherme de Souza Nucci, CPP Comentado, 6ª ed. RT, 2ª tiragem, maio de 2007, pág. 929), que bem justifica a prisão, na forma do artigo 387, parágrafo único do Código de Processo Penal.

"Em suma, para conciliar todos esses dispositivos e possíveis contradições, deve ser formulada a seguinte interpretação, com as seguintes alternativas: - se o acusado foi preso em flagrante ou por decreto de prisão preventiva, não pode ter fiança ou outra liberdade provisória, inclusive e especialmente após a sentença condenatória - o § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, ou o agora comentado, somente pode ter sua aplicação cogitada se o acusado estava solto até a sentença condenatória." (Lei de Drogas Anotada, Vicente Greco Filho e João Daniel Rossi, editora Saraiva, 2007, p.181).

("Não há direito de apelar em liberdade para quem já se encontra preso por força de custódia preventiva, não obstante primário e de bons antecedentes. A norma do art. 594 do Código de Processo Penal só alcança quem ao tempo da sentença condenatória estava em liberdade.") - Boletim do Superior Tribunal de Justiça, n.12, p.62, referindo-se a HC 4.701-0, MG., Rel. Min. Fernando Gonçalves, 6ª Turma, j. em 12.8.1996;

- HABEAS CORPUS ". ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. Réu que permaneceu no cárcere durante toda a marcha processual. Condenação. Manutenção na prisão em virtude da sentença condenatória. Entendimento pretoriano prevalente. Legalidade. Ordem denegada. (TJ-MG; HC 1.0000.05.426655-6/000; Juiz de Fora; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Reynaldo Ximenes Carneiro; Julg. 27/10/2005; DJMG 24/11/2005).

Recomende-se o réu Isac.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome de Isac no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 18 de novembro de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA  
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA